WEBINAR · IDP · IBERC · GRUPO DE PESQUISA O DIREITO PRIVADO NO SÉCULO 21

As funções da responsabilidade civil

Transcrição organizada e explicada: a fala de cada palestrante, com esquemas

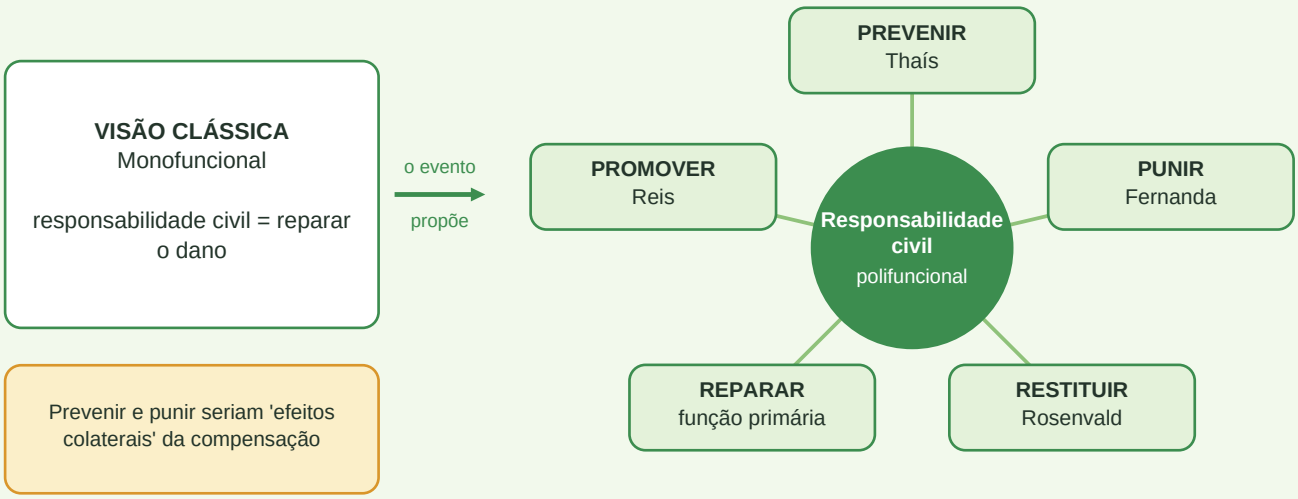
Palestrante	Função	Ideia em poucas palavras
Thaís Pasqualotto	Preventiva	A prevenção é o fundamento: olhar para o futuro, não só para o retrovisor
Fernanda Ivo Pires	Punitiva	O direito civil pode punir: a pena privada tem lugar legítimo
Antônio dos Reis Júnior	Promocional	Premiar quem repara o dano espontaneamente
Nelson Rosenvald	Restitutória	Quem lucra com o ilícito devolve o lucro

Moderação: Profa. Marília (magistrada, IDP). A transcrição de origem é automática e tem trechos truncados; onde isso afeta o conteúdo, o material avisa.

Antes de tudo: o debate do evento

A TESE COMUM

A responsabilidade civil deixa de ser **monofuncional** (só reparar danos) e passa a ser **polifuncional**: além de reparar, ela previne, pune, remove ganhos ilícitos e estimula a reparação espontânea. O evento foi montado para dar uma visão de conjunto, uma função por palestrante.



Por que a visão "só reparar" não basta (argumentos de Rosenvald)

- **Quase nenhum dano chega a ser compensado.** Nove em cada dez casos esbarram na dificuldade de provar o nexo causal ou no anonimato do dano.
- **Quando há compensação, muitas vezes quem paga é o seguro**, e o efeito sobre a conduta do ofensor desaparece.
- **Nem toda vítima quer dinheiro.** Em ofensas a direitos da personalidade, a tendência é a "desmonetização" da reparação.
- **Na responsabilidade objetiva, a análise da conduta desaparece.** Sem o juízo de reprovação, sobra só a conta a pagar.

O mapa das funções

Cada palestrante ocupa um ponto neste mapa. A função **reparatória** é a primária e ninguém a questiona; as demais discutem o que a responsabilidade civil faz **além** de reparar.



Para Thaís, a PREVENÇÃO é o fundamento que atravessa todas as funções

COMO ESTUDAR "FUNÇÃO" (método apresentado por Reis)

Análise **estrutural** pergunta "o que é isso?" e descreve elementos e requisitos. Análise **funcional** pergunta "para que serve?" e busca a finalidade. Todo o evento usa a segunda pergunta. Reis define a finalidade global da responsabilidade civil como **contornar o dano**, ou seja, resolver o problema do dano, e há várias maneiras de fazer isso.

1

PROFESSORA E ADVOGADA · DOUTORA PELA UFPR · AUTORA DE "A RESPONSABILIDADE CIVIL PREVENTIVA"

Thaís Pasqualotto

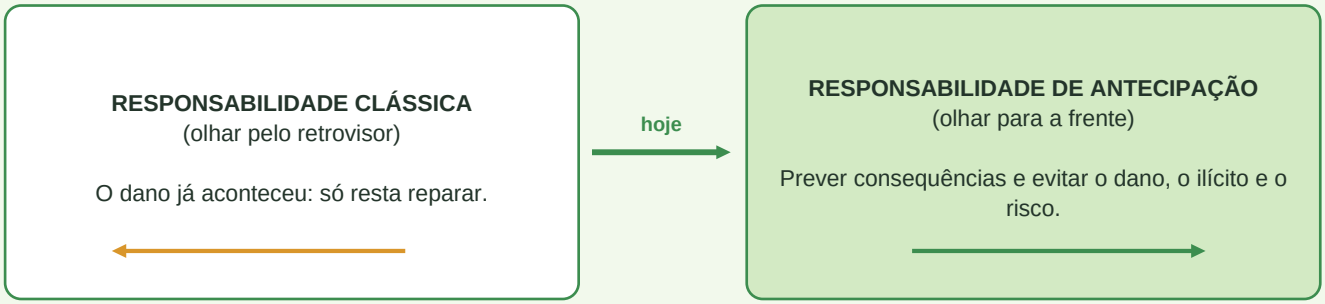
Função preventiva

EM UMA FRASE

A prevenção não é só uma função: é o **fundamento** da responsabilidade civil contemporânea, que precisa olhar para o futuro e não apenas para o dano já ocorrido.

1. O ponto de partida: o que significa ser responsável hoje?

Thaís parte de uma pergunta. Todo o sistema clássico da responsabilidade civil foi construído para **reparar**. Ela usa uma imagem atribuída a Geneviève Viney: esse sistema olha o dano **pelo retrovisor**, porque o dano já aconteceu e só resta repará-lo. Para ela, hoje é inegável que a responsabilidade precisa ser **voltada para o futuro**, uma responsabilidade de **antecipação**, que age por meio da prevenção de um dano, de um ilícito ou de um risco.

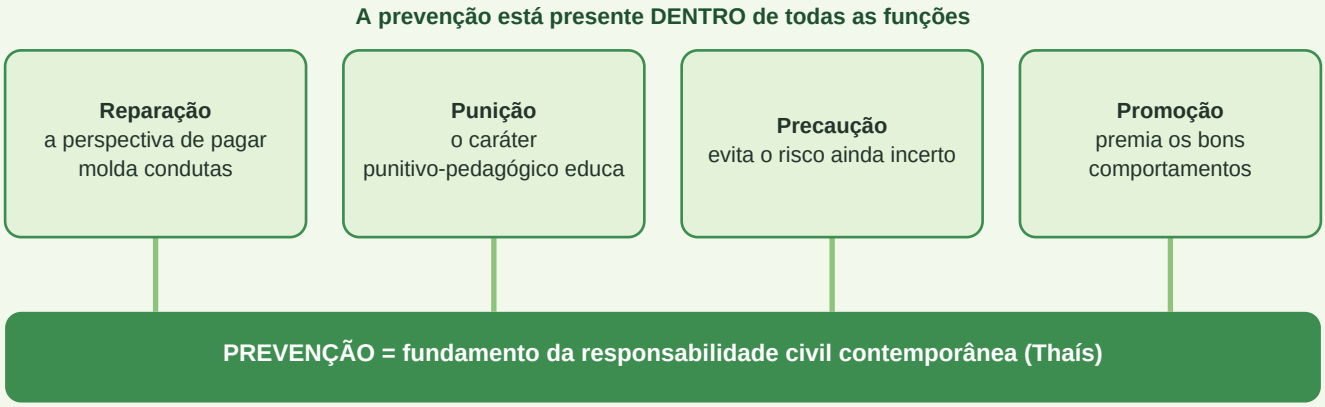


Ela liga isso à chamada **ética da responsabilidade**, voltada à proteção dos valores existenciais do ser humano: quem age não pode deixar de prever as consequências possíveis de suas ações e decisões. A transcrição grafa o autor como "uma febre"; pelo conteúdo, a referência provável é **Hans Jonas**. Isso explica também a mudança de sentido da própria palavra: responsabilizar já significou apenas reprimir, e hoje significa também agir prevendo.

2. Função, princípio ou fundamento?

Posição	O que diz
Prevenção como função	Uma finalidade da responsabilidade civil ao lado das demais.
Prevenção como princípio	Segundo ela, uma parte da doutrina diz que hoje a prevenção rege toda a responsabilidade civil.
Prevenção como fundamento (Thaís)	Vai além do princípio: a responsabilidade civil é um instrumento poderoso de direcionamento das condutas humanas e de desenvolvimento social, e é isso que a prevenção fundamenta.

Seja qual for o rótulo, a prevenção está no cerne. E, para Thaís, ela aparece **dentro de todas as funções**: na reparação, na função punitivo-pedagógica, na precaução e na promocional.

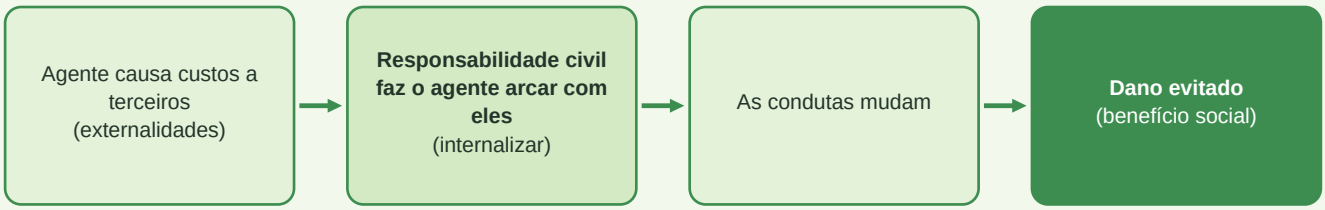


3. Por que a prevenção ganhou peso agora

- **Crescimento exponencial dos danos**, em quantidade e em qualidade. As novas tecnologias ajudam, mas trazem danos que ninguém imaginava. Exemplo: a **fake news** como dano coletivo e sistêmico, com alcance e profundidade capazes de comprometer um sistema democrático e eleitoral.
- **Ampliação do que se considera dano.** Condutas antes toleradas passaram a ser vistas como lesivas: criança sem cinto de segurança no carro ou bullying, que antes "faziam parte da vida". Por isso ela diz que as categorias de dano são exemplos didáticos, pois a cada dia surge um tipo novo.
- **Ressalva importante:** ela não é ingênua. Não existe sociedade sem dano, o sistema reparatório sempre existiu e continuará existindo, e a própria lógica de mercado convive com danos. A prevenção complementa, não substitui.

4. A Análise Econômica do Direito (AED) deu novo impulso

A aproximação entre direito e economia teve como pano de fundo a própria responsabilidade civil. Mesmo autores críticos da AED admitem que, nessa matéria, o diálogo é **imprescindível**. Para a AED, o maior benefício social das regras de responsabilidade **não é compensar** os danos, e sim **preveni-los**.



Para a Análise Econômica do Direito, o grande benefício social é prevenir, e não compensar

- **Por que não compensar?** Para compensar existem mecanismos melhores, como o **seguro**, que dá certeza da reparação. Mas Thaís lembra que o seguro tem problemas: quem pode contratá-lo no facultativo, e a socialização excessiva do prejuízo no obrigatório, que já se mostrou prejudicial.
- **Calabresi:** a obra sobre os custos dos acidentes é o marco da análise econômica da responsabilidade civil.
- **Calabresi e Melamed (Harvard Law Review):** o artigo sobre regras de propriedade, de responsabilidade e de inalienabilidade foi essencial nos estudos dela. A ideia: problemas de titularidade e de legitimidade do direito subjetivo geram altos **custos de transação**; protegê-lo antes da violação reduz esses custos. Na linguagem da AED, trata-se de **internalizar as externalidades**.
- **Críticas:** existem, sobretudo quando se trata de danos existenciais à pessoa, mas o instrumental teórico continua indispensável.

5. Como instrumentalizar a prevenção: a tutela inibitória material

Ela fala de prevenção em sentido amplo (**prevenção e precaução**). No direito ambiental a ideia já está bem desenvolvida; em outras áreas faltam mecanismos. A **tutela inibitória** (ordem para impedir ou interromper um ilícito) foi estudada, no Brasil, quase só pela doutrina **processualista** (a partir de estudos italianos, com Marinoni entre os autores citados). O problema: isso passa a impressão de que a inibição só nasce depois da violação de um direito.

A PROPOSTA DE THAÍS

Separar a **tutela jurisdicional** dos direitos (plano processual) da tutela no **direito material**. Ela propõe desenvolver uma **tutela inibitória material**: mecanismos preventivos previstos no próprio direito civil, e não apenas no processo.

Mecanismo citado	Observação
Multas coercitivas (*astreintes*)	Instrumento para forçar a cessação ou o cumprimento.
Caráter punitivo-pedagógico	Tema de Fernanda; a prevenção aparece de forma reflexiva.
Autotutela	Ada Pellegrini Grinover propõe uma releitura a partir de artigos do Código Civil.
Despesas preventivas	Tratadas em texto de Rosenvald. A transcrição cita o artigo do Código Civil de forma truncada ("925 25 1"); a referência provável é aos **arts. 249 e 251, parágrafo único** (credor que age por conta própria em caso de urgência e cobra depois). **Confirmar.**

6. Caso atual: a MP 966/2020 e a decisão do STF

A MP 966 trata da responsabilidade de agentes públicos por ações ou omissões nas decisões da pandemia. A grande questão é o conceito de **erro grosseiro**, e a MP foi inspirada no **art. 28 da LINDB**. A MP foi objeto de sete ações diretas de inconstitucionalidade no STF, com relatoria do ministro Barroso. Pelo trecho da transcrição, o relator deixou de analisar a lei da LINDB e seu decreto (em vigor havia mais de dois anos, sem urgência) e concentrou-se na MP. *(Esse trecho está truncado na transcrição; a leitura é interpretação.)* Foram fixadas duas teses:

TESE 1 (STF)
Configura erro grosseiro o ato que viola vida, saúde ou meio ambiente equilibrado por não observar os princípios da precaução e da prevenção.

TESE 2 (STF)
A autoridade deve exigir que os pareceres técnicos tratem expressamente de precaução e prevenção; senão, torna-se corresponsável.

Leitura de Thaís: precaução e prevenção entram na caracterização do erro grosseiro do agente público

7. Perguntas do debate respondidas por ela

Pergunta	Resposta em síntese
Onde o juiz acha base legal para aumentar o dano extrapatrimonial com caráter punitivo?	A prevenção sempre apareceu de forma reflexiva no caráter punitivo-pedagógico. O parágrafo único do art. 944 só fala em diminuir, mas, como Fernanda mostrou, o artigo trata de dano material. Os tribunais, inclusive o STJ, reconhecem o caráter dúplice; ela cita um recurso repetitivo do STJ sobre dano ambiental (**Tema 707**) e a posição da ministra Isabel Gallotti. O punitivo deve ser **instrumento** para quando há opção deliberada pelo dano, e não regra geral.
Mediação como realização da tutela inibitória?	Ficou para resposta posterior (pergunta citada pela moderadora). No debate, ela relata que muitas vítimas na mediação querem **pedido de desculpas ou retratação**, e que o desafio é mudar a postura de empresários.

A CRÍTICA DELA AO RÓTULO "DIREITO DE DANOS"

A responsabilidade passou por fases: primeiro o foco no ofensor, depois na vítima. Mas é preciso pensar na pessoa **antes** de ela virar vítima. Focar só na vítima ignora a conduta do agente, que muitas vezes opta pelo ilícito lucrativo porque compensa. O caminho é um equilíbrio: "nem tanto ao céu, nem tanto à terra".

CONFERIR ANTES DE CITAR

Calabresi e Melamed: o artigo é de 1972 (a fala "85" refere-se ao volume da revista). Número do repetitivo: a transcrição dá só "Tema 707" e uma numeração truncada (provável REsp 1.374.284/MG). Artigo do CC sobre autotutela: truncado. Autor da "ética da responsabilidade": provável Hans Jonas.

2

DOUTORA PELA PUC-SP · AUTORA DE "RESPONSABILIDADE CIVIL: O EFEITO PUNITIVO DA REPARAÇÃO" (2014)

Fernanda Ivo Pires

Função punitiva

EM UMA FRASE

O direito civil pode punir, e isso não é invasão do direito penal: a **pena privada** responde a uma exigência de eficácia social.

1. A ideia central e o método

Para Fernanda, buscar as funções da responsabilidade civil é saber de onde viemos, para onde vamos e a quem a aplicamos. O direito é **ciência social** e precisa ter eficácia na sociedade: o jurista não pode construir teoria sem sair do gabinete e ver como a sociedade se comporta. Citando o professor Renan Lotufo, ela diz que o direito civil deveria ser feito "pelo povo e para o povo". A pena privada seria uma resposta a esse anseio.

2. A base: os princípios do Código Civil de Reale



As três funções são facetas de um mesmo princípio maior

A pena privada aparece primeiro no anseio da **eticidade** (valorizar a pessoa humana em todos os seus aspectos, inclusive os valorativos). Mas o indivíduo não pode ser destacado da coletividade, daí a **socialidade**. E o direito precisa funcionar, daí a **operabilidade**. Ela faz um comentário curioso: o verdadeiro "operador do direito" não seria só o juiz, o advogado ou o promotor, mas a própria **coletividade**. Seu pensamento final aqui é que prevenir, reparar e punir são **facetas de um princípio maior, a função social**. Ela compara o direito a um organismo em que cada função existe para o funcionamento do todo.

3. As duas grandes críticas e as respostas dela

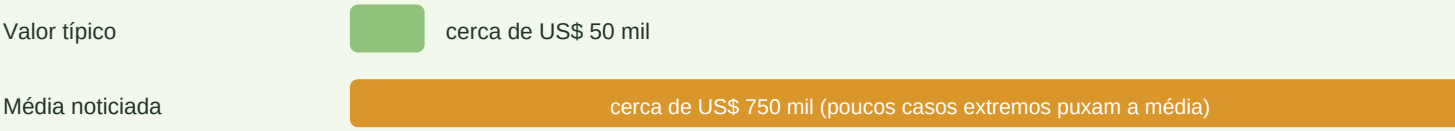
Crítica	Resposta de Fernanda
"Punir é coisa do direito penal"	Historicamente o direito civil esteve próximo do penal e sempre teve penalidades. O Código Civil já tem exemplos: **cláusula penal**; o **possuidor de má-fé** que perde as benfeitorias úteis sem indenização; regras de **acessões** nos direitos reais. E o direito civil "atinge onde mais dói": o patrimônio. Ela cita que, em ilícitos ligados à política, há quem prefira ser preso a ter o patrimônio atingido.
"É cópia do sistema norte-americano"	Estudar o direito comparado não é transplantar. Vários países europeus (Itália, Espanha, França) discutem ou admitem a ideia, e o **Código Civil do Quebec** (Canadá) prevê expressamente a punição. Ela vê ainda uma **reaproximação com o direito romano**, uma releitura do Corpus Iuris Civilis. Ela cita também Paulo Gallo, autor italiano de referência sobre a pena privada.

4. A "indústria do dano moral"

A crítica é que punir criaria uma "indústria" de ações. Ela rebate com estudos americanos dos anos 80 e 90: o número de ações de reparação por dano moral **não cresceu** de forma relevante. O que parecia crescimento era efeito de poucos **casos isolados com valores vultosos** que puxavam a média para cima. Para ela, o que existe é mais uma "indústria da **lesão**" do que do dano moral.

"Indústria do dano moral"? Valores citados na fala sobre os EUA (anos 80 e 90)

O número de ações ficou relativamente estável, segundo a palestrante.



Os valores acima são os citados na fala; a transcrição é imprecisa nesse trecho.

5. Para quem vai o valor? A pena é "privada"

Parte da doutrina propõe que a parcela punitiva da indenização vá para **fundos especializados**. Fernanda pensa diferente: a punição deve **reverter em favor da própria vítima**, e por isso fala em pena **privada**.

x

Parte da doutrina
A parcela punitiva vai para fundos especializados.

Fernanda
A punição reverte à própria vítima: por isso é "pena PRIVADA".

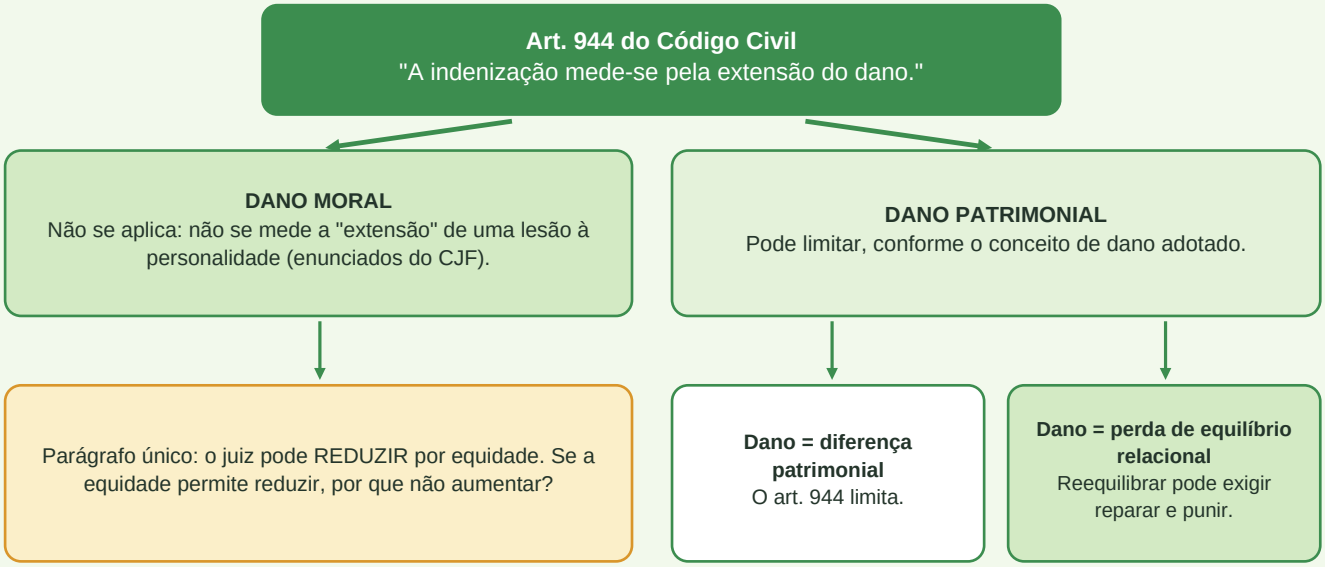
6. Culpa e responsabilidade objetiva

- A responsabilidade objetiva é **fundamental**: nasceu da equidade e da solidariedade, porque a vítima tinha enorme dificuldade de provar a culpa, e evoluiu para cobrir riscos de atividades úteis à coletividade.
- Mas existem **dois sistemas** e a objetiva não deve ocupar todo o espaço. Falar de punição é falar de **culpa** e de sua graduação.
- Ela nota que, em atividades abusivas e recorrentes de grandes empresas, a responsabilidade objetiva pode até ser **mais cômoda** para o ofensor, e que o STJ já admite dano moral mesmo na responsabilidade objetiva.

7. Os obstáculos técnicos

Enriquecimento sem causa da vítima. A causa existe: está na **ilicitude** do ofensor. Ela propõe pensar a causa como **função social**: certas condutas afastam o agente da função social esperada da responsabilidade civil.

Art. 944 do Código Civil. O artigo diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, o que parece barrar um valor punitivo.

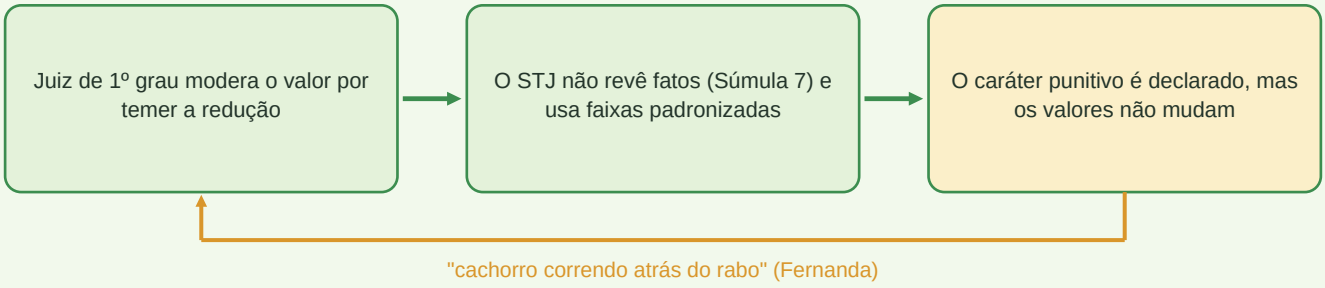


COMO ELA DEFINE "DANO"

Dano é a perda de um equilíbrio relacional, seja na relação contratual, existencial ou patrimonial. O reequilíbrio se dá pela reparação, que muitas vezes passa pela **punição** da ausência de cuidado, da falta de zelo e da violação da boa-fé objetiva, que ambas as partes devem observar em qualquer relação. A punição é parte do reequilíbrio, e não um extra externo.

8. A crítica à Súmula 7 do STJ (no debate)

Perguntada se indenizações de R$ 2 a 5 mil estimulam a reincidência, ela diz que não dá para afirmar em abstrato que esses valores são baixos: é preciso ver o caso concreto. Mas aponta um problema real: os tribunais atribuem quase por unanimidade caráter punitivo-pedagógico, **sem coragem de "pesar na caneta"**. E a Súmula 7 (que impede o STJ de reexaminar fatos) cria um círculo vicioso:



A CRÍTICA FINAL AO RÓTULO "DIREITO DE DANOS"

A responsabilidade civil não tem como foco só a reparação do dano. Tem **início, meio e fim**: prevenção e precaução no início; reparação e punição no meio; e efeito de desestímulo para **toda a coletividade**, não só para o condenado. Ela fecha com Reale: o código é um sistema aberto a princípios como a equidade e a boa-fé.

CONFERIR ANTES DE CITAR

Os enunciados do CJF sobre o art. 944 e o dano moral foram citados sem número (ver as Jornadas de Direito Civil). A editora do livro está grafada de modo impreciso na transcrição ("guarim", 2014). Sobre a posição de que o valor vai à vítima: é uma tese própria, minoritária frente à dos fundos.

3

DOUTOR PELA UERJ · ESPECIALISTA EM DIREITO PRIVADO EUROPEU (COIMBRA) · DIRETOR-ADJUNTO DO IBERC

Antônio dos Reis Júnior

Função promocional

EM UMA FRASE

O direito pode **premiar** quem repara o dano espontaneamente, em vez de só castigar. Reis diz que é a "mais neófita" das funções.

1. De onde vem a ideia

O tema não nasceu com ele: a discussão tem cerca de uma década, e ele atribui a Rosenvald um dos primeiros tratamentos técnicos. O que ele diz ter feito, na tese de doutorado, foi dar **sistematicidade e conteúdo próprio** à ideia, para que ela fosse autônoma e não se confundisse com as demais funções. O livro ainda estava no prelo na data do evento.

2. A base teórica: sanção negativa e sanção positiva (Bobbio)

SANÇÃO NEGATIVA	SANÇÃO POSITIVA
• Reação do direito ao ilícito: mal por mal • Base da coercibilidade do direito • Usada quando a conduta deve ser obrigatória • Reis não a critica: é essencial	• Premia quem se comporta bem • Para condutas importantes, mas não obrigatórias • O Estado não força ninguém a ser "pessoa ótima", mas pode incentivar • Dá efetividade à solidariedade

Base teórica: Norberto Bobbio, citado por Reis

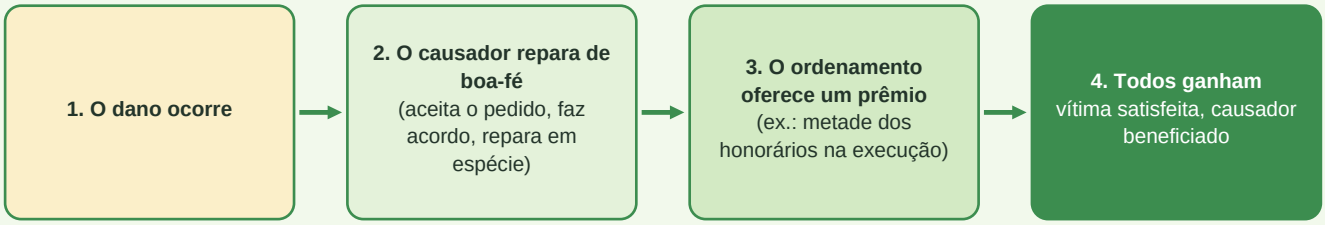
Ele observa que até juristas positivistas como Kelsen admitem que o direito tem uma função promocional genérica, ainda que a considerem "rarefeita". O critério para escolher entre uma e outra sanção é a **importância do bem jurídico**: se a conduta precisa ser obrigatória, usa-se a sanção negativa; se é importante, mas não a ponto de poder ser imposta, usa-se o prêmio.

3. O que é a função promocional

DEFINIÇÃO

É a função da responsabilidade civil que estimula a reparação espontânea do dano. "Reparação" aqui é em sentido amplo: aceitar o pedido da vítima, fazer acordo (autocomposição) ou reparar em espécie, com um serviço, um produto ou uma atividade.

O personagem que ele tem em mente é o "**bom sujeito**": o agente que normalmente age para prevenir danos, mas que, numa sociedade de risco e de acidentes, pode causar um dano a qualquer momento. Se ele busca reparar de boa-fé, merece ser **estimulado**, e para isso precisa haver prêmios ou bonificações previstos. A vítima que colabora também é "premiada".



Função promocional: estimular a reparação ESPONTÂNEA depois do dano

4. Como ela se diferencia das outras funções

Função	Momento	Instrumento	O que busca
Preventiva	**Antes** do dano	Pode usar sanção positiva, mas não só ela	Evitar o dano
Reparatória	Depois do dano	Teoria da diferença; reparação integral	Retirar todo o dano, nem mais nem menos
Punitiva / restitutória	Depois do ilícito	Sanção negativa	Castigar ou remover o ganho
Promocional	**Depois** do dano	**Sanção positiva** (prêmio)	**Satisfazer o interesse da vítima**, que pode não coincidir com a reparação integral

EXEMPLO PARA ENTENDER (do material)

Dano calculado em R$ 100 mil. Na lógica reparatória, a vítima tem direito aos R$ 100 mil. Na promocional, se ela aceita R$ 70 mil em 15 dias, ou um serviço equivalente, porque isso a satisfaz mais do que esperar anos por uma sentença, a função promocional estimula e protege esse resultado. (Exemplo ilustrativo, não é da fala.)

5. Vantagens para os dois lados

Para a vítima	Para quem causou o dano
Rapidez: recebe a solução mais cedo, mesmo que não seja a reparação integral clássica.	**Menos incerteza e menos despesas** (custas, honorários, imprevisibilidade da condenação).
Economia: evita honorários contratuais, risco de sucumbência, custas, deslocamentos e provas técnicas.	**Defesa mais forte** se for processado depois: o pagamento prova o fato extintivo ou impeditivo do direito do autor. Mesmo se o acordo for anulado, o que foi pago abate a condenação.
Fim da incerteza ("sepultamento da incerteza") sobre ganhar ou perder.	**Ganho de imagem**, sobretudo para empresas em relações de consumo e de interesse coletivo (ele cita empresas que, após tragédias, criaram canais diretos de reparação, ainda que persistam problemas).
Reparação em espécie: serviços, produtos ou atividades que atendam melhor que dinheiro.	**Prêmios previstos em lei** (veja abaixo).
Menor custo emocional do litígio.	**Mercado:** consumidores consultam avaliações de empresas antes de comprar, o que cria incentivo a resolver bem os conflitos.

6. Onde já existe sanção positiva no ordenamento

- **Redução pela metade dos honorários** quando o executado paga espontaneamente na execução (CPC/2015). Reis chama isso de "claramente um prêmio, claramente uma sanção positiva". O dispositivo exato não é dado na fala; por memória, creio ser o **art. 827, § 1º** (**confirmar**).
- **Agências reguladoras:** a reparação espontânea pode ser considerada ao aplicar penalidades administrativas (ele diz que traz exemplos na tese).
- **Redução de custos de indenização** quando a reparação foi feita por transação.

> **LIMITES RECONHECIDOS POR ELE**
> Faltam **sistematização** e regulação melhor: as previsões estão dispersas no ordenamento. E é preciso cuidado com situações de **vulnerabilidade**, para que um acordo não seja imposto a quem está em posição frágil.

7. O caso da moderadora (Marília)

Depois da fala, a moderadora (magistrada) traz um dado: na vara dela há altos índices de acordo em pedidos **só de dano moral**, com reparações **não pecuniárias**. Exemplo: uma pessoa transexual ofendida em uma pastelaria aceitou, em vez de indenização, dar uma **aula de cidadania** aos funcionários do estabelecimento. O gerente fretou um ônibus e levou a equipe ao fórum. As duas partes saíram satisfeitas. O interesse da vítima era o reconhecimento e a educação, e não a quantia, e esse é exatamente o ponto de Reis.

> **CONFERIR ANTES DE CITAR**
> Nem toda a doutrina aceita a promocional como função **autônoma**; há quem a veja como desdobramento da preventiva ou da reparatória. Cite como "segundo Antônio dos Reis Júnior", e não como regra legal. Confirmar o artigo do CPC e se o livro dele já foi publicado.

4

PROCURADOR DE JUSTIÇA (MP-MG) · PÓS-DOUTOR (ROMA TRE E COIMBRA) · PRESIDENTE DO IBERC · AUTOR DE "A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ILÍCITO LUCRATIVO"

Nelson Rosenvald

Função restitutória

EM UMA FRASE

Quem lucra com um ilícito deve **devolver o lucro**: a resposta do direito precisa se medir pelo **ganho do ofensor**, e não só pelo dano da vítima.

1. Abertura: três palavras onde o português tem uma

Rosenvald propõe estudar a "**filologia** da responsabilidade". Em português há uma palavra só; em inglês, três. Isso ajuda a sair da **monofuncionalidade** para a **polifuncionalidade**. Ele também rejeita a tese de que prevenção e punição seriam "efeitos colaterais" da compensação, e apoia a crítica de Fernanda ao rótulo "direito de danos".

Em português há uma palavra só. Em inglês, três.

LIABILITY
indenizar danos
= visão clássica

RESPONSIBILITY
responsabilidade moral
= funções punitiva e promocional

ACCOUNTABILITY
prestar contas, precaver
= função preventiva

Uma palavra só nos prende à monofuncionalidade (Rosenvald)

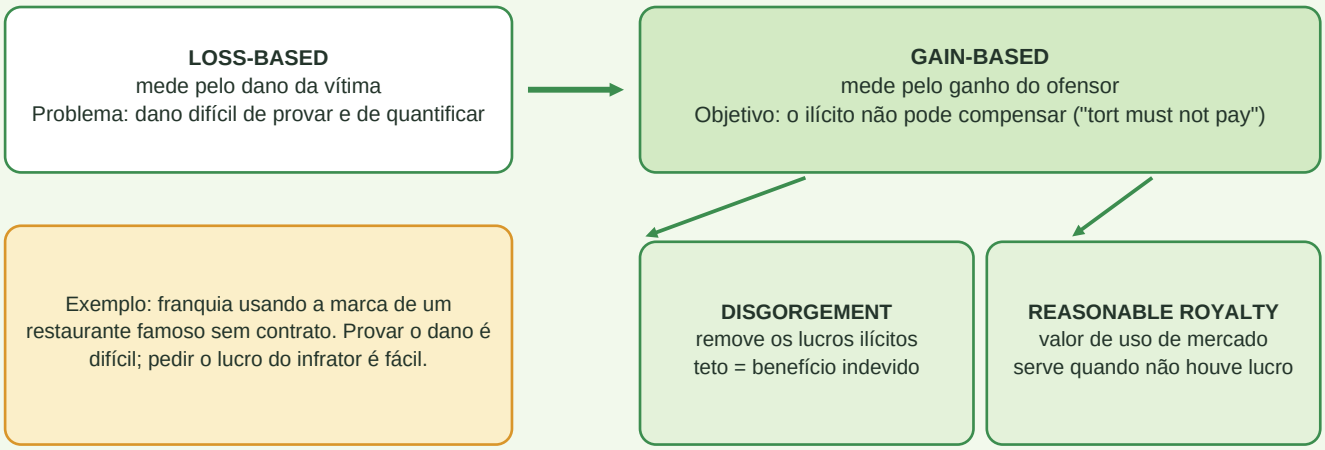
2. O problema: o ilícito lucrativo

Hoje existe uma proliferação de danos e também de **ilícitos lucrativos**. Os agentes econômicos têm "uma máquina de calcular": se o lucro com a atividade ilícita for maior que a indenização, vale a pena. O princípio inglês é que o ilícito "não deve compensar" (*tort must not pay*). Ele dá exemplos em quatro campos:

Campo	Exemplo dado
Direitos da personalidade	Uso da imagem e da intimidade de alguém, lucrando muito mais do que a indenização.
Propriedade imaterial	Uso de patentes, direitos autorais e dados pessoais.
Direitos individuais homogêneos	Cobrança de 20 centavos a mais em milhões de contas: cada dano é pequeno, o conjunto é muito lucrativo.
Direitos metaindividuais	Empresa que continua lucrando mesmo após desastres ambientais.

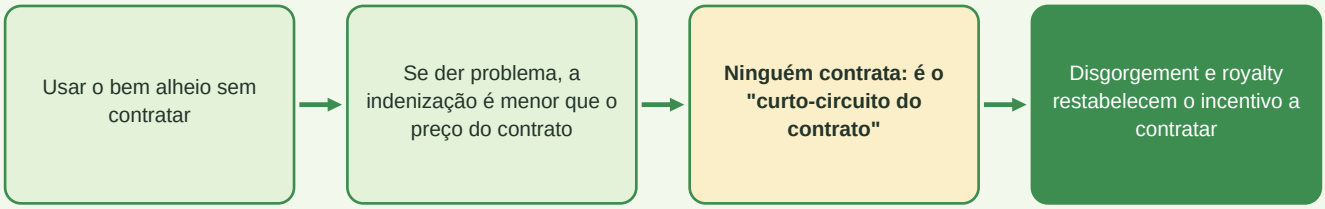
3. A virada: do dano ao ganho

A reação ao ilícito lucrativo começou na Inglaterra, ao passar de uma lógica **loss-based** (indenizar o dano) para **gain-based** (olhar o ganho). A responsabilidade civil deixa de se preocupar só com a contenção de danos e passa à contenção de ilícitos: prevenção de riscos, punição de ilícitos e **restituição de lucros ilícitos**. A função restitutória se divide em dois remédios.



Remédio 1: Disgorgement (remoção dos lucros ilícitos)

- **Exemplo:** alguém abre uma franquia usando a marca de um restaurante famoso sem contrato. Para o dono da marca, provar e quantificar o dano é muito difícil, mas ele pode pedir a **remoção dos lucros** do infrator.
- **Não é enriquecimento injustificado:** o lucro do infrator é "justificado", mas **por um ato ilícito**.
- **Sentido econômico:** evitar o "**curto-circuito do contrato**". Em países de instrumental jurídico frágil, muita gente prefere usar o bem alheio sem contratar, porque a indenização futura será menor que o preço do contrato.



Explicação econômica do disgorgement

- **Explicação kantiana (Ripstein, 2017):** se alguém pega 10 dólares de outro e os aplica, obtendo 50, deve devolver os 50 (e não só os 10). Ao tirar o dinheiro, violou a autodeterminação da vítima, que passou a ser instrumento da vontade alheia.
- **Diferença para os danos punitivos:** o teto do disgorgement é o **benefício indevido**, e a finalidade é remover o lucro. Os punitivos sancionam condutas especialmente reprováveis (exemplo dado: o motorista de um racha que atropela alguém), e o valor **pode superar** qualquer lucro.

Remédio 2: Reasonable royalty (valor de uso de mercado)

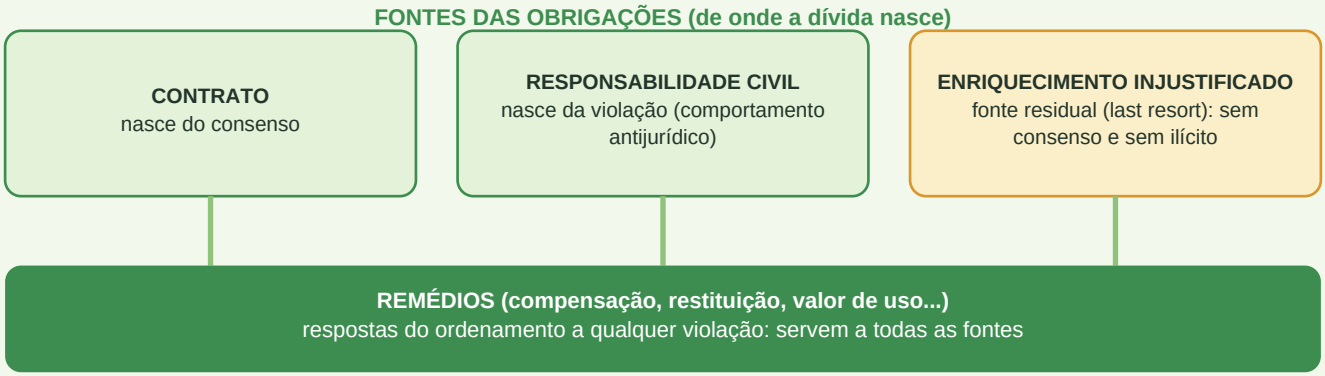
- **Quando serve:** o ofensor usou o bem alheio, mas **não teve lucro** (ele dá o exemplo de usar a patente de alguém sem ganhar nada com isso). Ainda assim, economizou o preço de uma licença, e o titular pode cobrar o **valor de mercado** pelo uso.
- **Natureza:** uma "barganha hipotética", o contrato que as partes teriam feito. **Não são lucros cessantes**, que é outra coisa.
- **No Brasil:** o **art. 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)** reúne três remédios para quem usa a patente alheia: lucros cessantes, valor de uso e lucros do infrator. É, segundo ele, o único caso em que os três convivem pacificamente.

4. O direito europeu: a vítima escolhe

A União Europeia adota uma abordagem **pragmática**. No projeto de código das obrigações (DCFR), na diretiva de propriedade intelectual (2004) e na de segredo comercial (2017), a vítima tem **três opções**: a compensação tradicional (danos emergentes e lucros cessantes), o **valor de mercado** ou o **disgorgement**. Ele chama isso de **private enforcement**: a vítima tem autonomia privada para escolher o melhor remédio e deixa de ser agente passivo, passando a agente regulador do mercado naquele caso. Ele conecta isso à **tutela inibitória material** de Thaís e diz que o direito civil precisa dar um passo além do discurso dos direitos fundamentais, para uma **perspectiva remedial**: como dar o remédio.

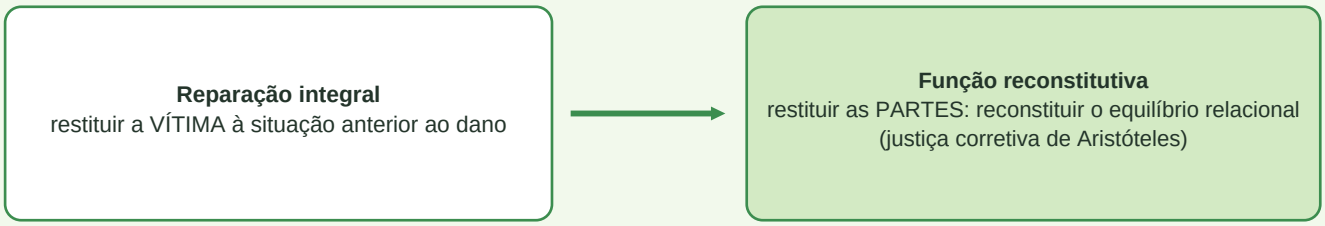
5. A crítica ao STJ: fontes das obrigações x remédios

No caso **Giovanna Antonelli**, a atriz teve a imagem usada sem autorização e, em vez de pedir reparação de danos, pediu o **lucro ilícito**. O STJ concedeu, mas pelo caminho do **enriquecimento injustificado**. Rosenvald discorda: o STJ parte da premissa de que a responsabilidade civil só serve para indenizar danos (art. 944) e que, para sair disso, é preciso ir ao enriquecimento. Ele diz que o STJ seguiu uma noção do direito alemão, que aplica o enriquecimento de forma muito ampla por particularidades que não cabem num transplante ao Brasil. A distinção que ele propõe, apoiado em Birks (**não confundir os dois níveis**):



- O enriquecimento injustificado é **residual**: só vale quando a obrigação não nasce de consenso nem de comportamento antijurídico.
- A **restituição é um remédio** e pode ser usada em qualquer fonte, inclusive nos contratos e na responsabilidade civil. Restituição e enriquecimento injustificado "não são irmãos siameses".

6. Proposta final: da "reparação integral" à função reconstitutiva



Pensar a responsabilidade civil como "restituir a vítima à situação anterior ao dano" é, para ele, um erro. Melhor falar em função **reconstitutiva** (como no Código Civil português): reconstituir o **equilíbrio relacional** entre as partes. Às vezes isso se dá pela reparação de danos; outras, **restituindo o ofensor** à situação anterior ao ilícito, removendo seus ganhos ou cobrando o valor de uso. Ele se apoia na **justiça corretiva de Aristóteles**, que é bilateral, e diz que "o grande erro nosso foi não ter ouvido Aristóteles e ter ouvido Santo Agostinho". (Essa comparação final é interpretação dele.)

7. A pergunta do debate: dá para cumular os remédios?

Pergunta de Reis: é possível pedir parte do valor como compensação, parte como disgorgement e parte como valor de uso? Rosenvald diz que **não**: para ele são caminhos **alternativos**. Quem opta pela responsabilidade na função compensatória deve ficar nela; quem mira o ofensor e o lucro vai por outro caminho. Ele reconhece que há colegas no direito brasileiro que admitem a cumulação ("fracionada"), e que o ponto é controvertido. No fim do debate, ele propõe um segundo encontro sobre as **fragilidades da função compensatória**.

CONFERIR ANTES DE CITAR

Art. 210 da LPI: confirmar a redação vigente. A referência a Birks na transcrição está garbled ("birds"); o nome mais provável é Peter Birks. O livro de Ripstein é de 2017 (a transcrição diz "drive home"; título a confirmar). A cumulação dos remédios é ponto controvertido: há autores que a admitem.

Como as quatro falas se encaixam

	Thaís	Fernanda	Reis	Rosenvald
Função	Preventiva	Punitiva	Promocional	Restitutória
Momento	Antes do dano	Depois do ilícito	Depois do dano	Depois do ilícito
Tipo de sanção	Positiva ou negativa	Negativa	Positiva	Negativa (remove ganho)
Pergunta central	Como evitar o dano?	Como desestimular a conduta grave?	Como estimular a reparação espontânea?	Como evitar que o ilícito compense?
Medida	Risco e conduta futura	Gravidade da conduta (culpa)	Interesse da vítima	Ganho do ofensor ou valor de uso
Instrumentos citados	Tutela inibitória material, astreintes, autotutela	Pena privada, caráter punitivo-pedagógico	Prêmios, acordos, reparação em espécie	Disgorgement, reasonable royalty
Conceito-chave	Ética da responsabilidade; AED	Dano como perda de equilíbrio relacional	Sanção positiva (Bobbio)	Ilícito lucrativo; remédios x fontes

Pontos de convergência

- "**Direito de danos**" é um rótulo reducionista. A responsabilidade civil é polifuncional.
- É preciso olhar também para a **conduta do agente** e para o **equilíbrio entre as partes**, e não só para a vítima.
- A **vítima** deve ter mais autonomia para escolher o remédio adequado (desculpas, retratação, reparação não pecuniária, valor de uso, lucro do ofensor).
- Enquanto o ilícito compensar financeiramente, ele continuará: a resposta precisa "doer no bolso".
- A **mediação e a autocomposição** têm papel crescente.
- Todos usam a ideia de **equilíbrio relacional** (Fernanda e Rosenvald) e de prevenção reflexiva em todas as funções (Thaís).

Observações da moderadora (prática judicial)

Magistrada, ela observa que os juízes já aplicam punição de modo **implícito**: majoram indenizações contra grandes litigantes sem dizer que estão punindo, em função do número de processos e da incidência do problema. Para ela, a resistência talvez seja tributária da tradição da função reparatória, e a decisão "não pode ser uma caixinha de surpresa": é preciso **transparência** sobre por que o valor foi majorado.

Perguntas do chat e do YouTube

Pergunta	Quem respondeu	Resposta
Base legal para majorar o dano extrapatrimonial com caráter punitivo?	Thaís	Prevenção reflexiva no caráter punitivo-pedagógico; tribunais e STJ reconhecem o caráter dúplice; punitivo como instrumento excepcional.
Indenizações de R$ 2 a 5 mil estimulam a reincidência?	Fernanda	Depende do caso concreto; críticas à Súmula 7 e à falta de coragem de "pesar na caneta".
Dá para cumular compensação, disgorgement e valor de uso?	Rosenvald	Não: são pretensões alternativas. Ponto controvertido.
Mediação como forma de tutela inibitória?	(pendente)	Ficou para resposta posterior, por falta de tempo.

COMO USAR ESTE MATERIAL COM RIGOR

São posições de **doutrina**: algumas consolidadas, outras teses em debate (a função promocional como autônoma, a função reconstitutiva, a cumulação de remédios). Em trabalho ou prova, escreva "segundo [autor]" e não "a lei diz". O art. 944 continua em vigor e há quem defenda que ele limita a indenização. A fonte é transcrição automática: confira nomes, artigos e números citados antes de usar em texto acadêmico.